

C3.<sup>a</sup> CC Cba. 5/10/21. Sentencia N° 115. Trib. de origen: Juzg. 31<sup>a</sup> CC Cba.  
"Reyna, Oscar Ignacio c/ Cúneo, Sebastián y otro - Abreviado - Daños y Perjuicios  
- Accidentes de tránsito - Trámite oral - Expte. Nro. 5816212"

2<sup>a</sup> Instancia. Córdoba, 5 de octubre de 2021

¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora?

El doctor Rafael Garzón dijo:

En estos autos caratulados (...) venidos del Juzgado de 1.<sup>a</sup> Inst. 31.<sup>a</sup> Nom. CC Cba.,  
a los fines de resolver\_ 1) el recurso de apelación interpuesto con fecha 8/6/20 por  
la citada en garantía Liderar Cía. Gral. de Seguros SA. y 2) el recurso de apelación  
deducido el día 10/6/20 por la parte actora, ambos en contra de la sentencia N.º 48  
de fecha 22/4/20, que resolvió: "I) Rechazar la defensa de falta de acción opuesta  
por los demandados Sebastián Cúneo y Roberto Damián Barrionuevo. II) Hacer  
lugar a la demanda incoada por Oscar Ignacio Reyna en contra de Sebastián Cúneo  
y Roberto Damián Barrionuevo y, en consecuencia, condenar a estos últimos a  
abonar a la actora en el plazo de 10 días y bajo apercibimiento de ley, la suma de  
\$30.495,84, con más los intereses establecidos en el considerando respectivo hasta

el efectivo pago, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Liderar Compañía General de Seguros SA en la medida de su cobertura, desestimando la declinatoria formulada por la aseguradora. III) Imponer las costas a los demandados Sebastián Cúneo y Roberto Damián Barrionuevo haciendo extensiva la condena a la aseguradora citada en garantía Liderar Compañía de Seguros Generales SA en la medida de su cobertura [...]". I. Preliminar: El recurso de apelación de que se trata ha sido interpuesto en el término y con las formalidades prescriptas por el art. 366, CPCC, y en contra de una resolución apelable, atento lo dispuesto por el art. 361 inc. 1), CPCC, razón por la cual ha sido correctamente concedido. Radicados los obrados en esta Sede, y mediante decreto de fecha 17/12/20 se ordena correr traslado al actor apelante Sr. Oscar Ignacio Reyna para que exprese agravios, quien lo evacua con fecha 29/12/20. Corridos los traslados para contestar agravios a los demandados Sres. Sebastián Cúneo y Roberto Damián Barrionuevo, éstos dejan vencer el plazo sin realizar presentación alguna. La citada en garantía contesta el traslado con fecha 29/3/21. Dictado el decreto de autos (16/4/21), firme y consentido, queda la causa en condiciones de dictar resolución.

II. El caso: El actor, Sr. Oscar Ignacio Reyna, promovió demanda ordinaria en contra de Sebastián Cúneo y Roberto Damián Barrionuevo por el cobro de la suma de \$68.894,81 con más sus intereses y costas con motivo de un accidente de tránsito que protagonizó el día 31/12/11 a las 20.30 en la avenida Donato Álvarez. Dijo haber sido embestido por el automóvil afectado al servicio de remis marca Fiat Uno dominio FFG 335 (Empresa Auto Expres, Móvil 111), cuando circulaba

en su ciclomotor y atribuyó las consecuencias dañosas en su persona y en sus bienes -exclusivamente- a los accionados. Pidió ser resarcido conforme el siguiente detalle: a) "Daño emergente - valor del rodado" por la suma de \$5.000; b) Daño emergente - Gastos médicos por la suma de \$500; c) Lucro cesante futuro por la suma de \$48.394,81 y d) Daño moral por la suma de \$15.000 o lo que en más o en menos resultara de la prueba a rendirse. En lo que aquí nos interesa, pidió se calculara lucro cesante futuro mediante fórmula Marshall calculado con el salario mínimo, vital y móvil al momento del hecho. Los demandados y la aseguradora comparecieron, contestaron la demanda y pidieron su rechazo, con costas. El Sr. juez de primera instancia receptó parcialmente la demanda deducida por la suma de \$30.495,84 conforme el siguiente detalle: 1) daño emergente - valor del rodado por un importe de \$8.000; 2) daño emergente - gastos médicos por \$500; 3) pérdida de chance por \$16.995,84 y 4) daño moral por \$5.000. En contra de dicho resolutorio se alza en apelación la actora. III. Expresión de agravios del actor: Con fecha 29/12/20 expresa agravios el actor Sr. Oscar Ignacio Reyna. 1) Primer agravio: Errónea nominación de rubro indemnizatorio como "pérdida de chance". Disminución económica injusta. Fundamentación defectuosa. Dice que el a quo, a los fines de cuantificar el monto indemnizatorio derivado de la incapacidad psicofísica del actor, propuso el cálculo actuarial de uso habitual en el fuero (abreviación de la "Fórmula Marshall") y luego de dicho cálculo procedió a una disminución del 50%, bajo la consigna de otorgar el rubro en concepto de pérdida de chances. Asegura que, para así fallar, comienza por transcribir doctrina

a la que adhiere (entre muchas posiciones encontradas en la materia) en orden a la distinción conceptual entre incapacidad sobreviniente, lucro cesante y pérdida de chance. Manifiesta que la doctrina elegida –de indudable prestigio, aunque elaborada más de dos décadas atrás – resulta luego eslabonada con jurisprudencia del TSJ referida a la incapacidad vital y la consecuente extensión del resarcimiento hacia la integridad psicofísica del individuo y no sólo en la faz productiva. Considera que esa concatenación efectuada por el magistrado resulta confusa en aras de determinar el iter lógico de su razonamiento. Afirma que, si la incapacidad a indemnizar excede la faz eminentemente productiva del damnificado, entonces, la supuesta merma de ingresos no podrá erigirse ya en la variable que determine el otorgamiento del rubro derivado de dicha incapacidad. Sostiene que si el magistrado sustenta o adhiere a una postura que consagra el resarcimiento a la integridad psicofísica –no sólo la productiva del sujeto –, resulta lógicamente contradictorio que luego proceda a disminuir su cuantificación en orden a la (concreta o previsible) disminución de ingresos. Dice que siguiendo los propios lineamientos que sustenta el a quo, la limitación de las repercusiones gravosas a la sola faz productiva del desarrollo personal del ser humano no se condice con los estándares actualmente sentados en materia de reparación integral sustentados por la máxima Magistratura de la Nación en el caso "Mosca", en el que se consideró "que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño

moral". Asimismo, pone de resalto que –en el caso concreto– el perito traumatólogo oficial ha realizado específica referencia a la incapacidad del actor sobre la "total humana" (baremo civil) y no a la denominada "total obrera". Afirma que una pérdida de ingresos concretamente demostrada no constituye per se, a la luz de la jurisprudencia actualizada de la mayoría de las Cámaras de esta circunscripción, el criterio para otorgar la indemnización del daño sin merma porcentual. Conforme lo argumentado, requiere se provea a una cuantificación sobre el cálculo actuarial que no contemple merma porcentual alguna, amén del nomen juris del rubro, conforme fuera requerido al demandar y alegar en autos. 2) Segundo agravio: Cálculo erróneo del rubro Lucro Cesante. Mínimo pretérito arbitrario. Disminución económica injusta. Motivación insuficiente. Dice que el a quo efectúa los cálculos matemáticos con base en el monto correspondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del hecho (diciembre del 2011). Sostiene que dicho criterio contiene un error conceptual, ya que el rubro indemnizatorio constituye una obligación de valor cuya cuantía, por ende, se debe establecer al momento temporal en que el sentenciante determina dicho valor. Manifiesta que, de lo contrario, se configuraría un evidente enriquecimiento sin causa en cabeza de los obligados al pago, quienes obtendrían de aquella forma un rédito económico fruto de la contingencia de la duración temporal del procedimiento, y ello amén de los intereses mandados a pagar en la sentencia. En definitiva, solicita se proceda al recálculo computando el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al tiempo de la sentencia de primera instancia, con más sus

accesorios desde la fecha de dicha determinación. IV. Contestación de agravios de la citada en garantía Liderar Cía. Gral de Seguros S.A.: Con fecha 29/3/21 contesta los agravios la citada en garantía. Dice que la parte contraria se ha limitado a manifestar su discrepancia de la resolución impugnada, sin demostrar, de modo alguno, cuál es el gravamen que le ha causado y que pueda ser revisado por vía de apelación. Advierte que esta falta de cumplimiento de los requisitos básicos de una correcta técnica impugnativa vulnera el debido proceso y el derecho de defensa amparados por nuestra Constitución Nacional. Dice que la apelante no indica cuál es el interés lesionado por la resolución y menos aún, cuál es el razonamiento correcto para el hipotético caso de que la resolución atacada contenga vicios que pudieran ser revisados por esta vía impugnativa. Por otra parte, sostiene que la sentencia dictada en autos cumple acabadamente con las reglas del correcto sentenciar. En función de ello, solicita se rechace el recurso de apelación incoado en todas sus partes con costas. V. Suficiencia técnica del recurso de apelación: Al contestar el traslado de la expresión de agravios, la citada en garantía ha controvertido la suficiencia técnica del recurso de apelación y ha solicitado su rechazo al sostener que no existe una crítica válida de la sentencia impugnada que permita tener por fundado el recurso. La expresión de agravios constituye una carga procesal que pesa sobre el impugnante en el sentido de que debe exponer jurídicamente, mediante el análisis razonado y crítico del fallo, los errores de la sentencia recurrida punto por punto y demostrar los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (Conf. Alsina, Hugo, Tratado de

Derecho Procesal, 2ª edición, IV, pág. 389). Expresar agravios importa analizar los fundamentos dados por el magistrado en la resolución que se impugna y realizar un análisis crítico y señalar los errores in iudicando, in procedendo o in cogitando, que ella posee. Nuestro Máximo Tribunal provincial ha señalado: "La expresión de agravios a que alude el art. 371 del CPCC implica una verdadera descalificación crítica del decisorio del iudex. Por ello exige de un preciso y concreto examen de los fundamentos de la sentencia apelada y una alusión clara de los yerros que -a juicio del impugnante- ella contiene" (Conf. TSJ, Sala Civil y Comercial, "Meraviglia Horacio c/ Capillita S.A. - Acción subrogatoria - Recurso directo", Sentencia N° 109 del 20/9/04). De otro costado, la deserción técnica de un recurso de apelación debe ser apreciada de manera restrictiva y, en caso de dudas, siempre debe estarse a la subsistencia del recurso de apelación. Ello a los fines de garantizar el acceso del judiciable a la doble instancia. Este criterio ha sido sostenido por nuestro Tribunal Superior de Justicia provincial en numerosos antecedentes: "En sustento de esta conclusión no puede dejar de puntualizarse que la consideración de la suficiencia de la expresión de agravios de los recursos ordinarios debe realizarse en forma laxa, esto es, que en caso de duda debe estarse por el mantenimiento de la apelación. En función de ello, la sanción prevista en el art. 374 del CPCC -en cuanto importa pérdida o caducidad de los derechos del apelante- debe ser interpretada con criterio restrictivo y reservada sólo para los casos en donde la falta de idoneidad del escrito presentado como expresión de agravios sea palmaria" (Conf. TSJ, Sala Civil y Comercial "Dirección de Rentas

de la Provincia de Córdoba c/ Cooperativa de Trabajo La Rural Ltda. - Procedimiento de ejecución fiscal administrativa - Recurso de casación (Expte. 2205199/36)", Sentencia N°.9 del 7/3/17). Asimismo, ha dicho que "la apelación es una vía impugnativa de carácter ordinario, por lo cual los jueces deben ser más bien amplios e indulgentes en la apreciación de la suficiencia crítica de los argumentos que se expresan para fundarla, y procurar siempre preservar la garantía constitucional de defensa en juicio, evitando incurrir en excesos de rigor formal (TSJ, sentencias Nros. 85/10, 23/12, 54/17, entre otras). De allí que la sanción prevista en el art. 374 del CPCC, en cuanto importa pérdida o caducidad de los derechos del apelante debe ser interpretada con criterio restrictivo (Conf. TSJ, Sala CC, en autos: "Cismondi, Juan o Giovanni - Declaratoria de Herederos - Incidente de exclusión de bienes promovido por Alfonso Cismondi - Recurso Directo", expediente Nro. 6511429. Auto Interlocutorio Nro. 35 del 5/3/18). Bajo estos parámetros, juzgo que la expresión de agravios contenida en el escrito presentado por el actor Sr. Oscar Ignacio Reyna satisface la exigencia legal desde que controvierte la reducción efectuada por el Sr. juez de primera instancia en el rubro pretendido como lucro cesante futuro, realizando una detallada comparación de doctrina y jurisprudencia que estima aplicable al caso, en virtud de lo cual el escrito impugnativo resulta suficiente a los fines de habilitar la competencia del tribunal de alzada. VI. El análisis de los agravios de la actora. La solución: Como punto de partida es dable destacar que tanto la existencia del accidente de tránsito que dio lugar a este proceso, la participación de la actora y los demandados, cuanto la



responsabilidad atribuida a los demandados, no han sido objeto de controversia en esta Sede. 1) El agravio referido a la "incapacidad". El actor recurrente ha criticado el fallo porque el sentenciante efectuó una disminución del 50%, bajo la consigna de otorgar el rubro en concepto de "pérdida de chances". Ha cuestionado que sólo haya valorado la faz laboral del daño y dejado de lado el menoscabo sufrido en los distintos ámbitos vitales del ser humano. Así planteada esta primera queja, corresponde repasar la línea argumental expuesta por el sentenciante en este punto. Y en esa tarea estimo necesario reproducir los segmentos del fallo que guardan estrecha vinculación con el tema en discusión: "En ese marco y como primera medida, tratándose de una cuestión jurídica, diferenciaré los conceptos de incapacidad sobreviniente, lucro cesante y pérdida de chance, debido a que, si bien tienen una misma raíz ontológica, son heterogéneos o disímiles a los fines prácticos de su determinación. En estricto sentido, siguiendo la distinguida doctrina elaborada por la Dra. Matilde Zavala de González, cabe sostener que la incapacidad sobreviniente prima facie no es indemnizable en sí misma, sino con motivo de las repercusiones económicas que provoca en la víctima, quedando comprendida en una noción amplia de lucro cesante consistente en la pérdida de ingresos o beneficios económicos de que fue privada la víctima con motivo del hecho dañoso. Esto así, la doctrina dominante distingue entre lucro cesante e incapacidad, no en función de la esencia misma del daño que implican, sino por las características de la situación lesiva que genera ese perjuicio (...) en el caso de la incapacidad sobreviniente se valora la minoración resultante en la capacidad

psicofísica del sujeto, que no ha logrado ser subsanada por vía terapéutica y que revista cierta perdurabilidad o se proyecta al resto de la vida útil de la víctima, pudiendo, desde el punto de vista patrimonial, dar lugar a lucro cesante presente o futuro, o pérdida de chance cuando se frustra una oportunidad de obtener un beneficio -si se trata de una contingencia razonable (...). Conforme lo hasta aquí expuesto, en abstracto y desde el punto de vista patrimonial, son distintas las exigencias probatorias, requiriéndose en el caso del lucro cesante la estricta acreditación de las ganancias y su cese y en el caso de la incapacidad sobreviniente, el daño es percibido de manera oblicua a partir de una plataforma inferencial, debiendo atenderse a su vez a las características particulares de cada caso, pues aun en el supuesto de la víctima sin ingresos al tiempo del siniestro, cabe indemnizar la pérdida de la oportunidad misma de obtenerlos a través de la frustración de "chances", debiendo tratarse de daño probable, es decir, previsible, verosímil, regular o "casi" seguro (...); por lo cual el daño, así definido, requiere que deba (a)meritarse de manera integral la situación del damnificado y sus consecuencias, a fin de establecer si ese hecho lesivo ha influido en forma disvaliosa en la persona. En ese contexto, toda vez que en caso de secuelas incapacitantes de la salud no sólo se indemniza la faz productiva sino la integridad psicofísica, que involucra la pérdida de capacidad vital en lo que toca a actividades propias de toda persona en su vida de relación, entiendo que en tales supuestos no se trata de un daño futuro en su capacidad lucrativa, y teniendo en cuenta que el actor en su demanda no invoca y menos acredita tener ingresos concretos sino que

arriba al monto indemnizable que reclama tomando en cuenta el salario mínimo vital y móvil, por lo que el reclamo debe ser abordado como pérdida de chance, toda vez que la víctima, no obstante no padecer una incapacidad total, soporta la privación de oportunidades de progreso e incluso con el consecuente riesgo de desocupación, en función de carecer de igualdad de oportunidades que una persona absolutamente sana frente a un mercado laboral deprimido en cuanto a las oportunidades de empleo que ofrece en la actualidad". Finalmente, para su cuantificación, utiliza la fórmula "Marshall" usando como base el salario mínimo vital y móvil al cual le aplica un porcentaje estimativo en concepto de frustración de chance, reducida 50% por tratarse de pérdida de chance conforme las circunstancias del caso. A los efectos de resolver el primer agravio introducido por la parte actora, hay que determinar si ha sido correcto que se decidiese que debe indemnizarse su incapacidad a título de pérdida de chance –con la consecuente disminución porcentual que ello supone respecto de la indemnización a título de lucro cesante – o si, en cambio, debe indemnizarse la incapacidad a título de lucro cesante. Sobre lo planteado vale realizar las siguientes consideraciones. El daño patrimonial gira alrededor de los beneficios materiales que el ser humano, menoscabado en su integridad y plenitud, hubiese podido lograr de no haber sufrido la situación lesiva y aminorante. Si bien las aptitudes del ser humano no tienen un valor económico intrínseco (en el sentido de que no constituyen bienes que estén en el mercado), sí puede encontrarse un valor de esa clase a título mediato, en cuanto instrumento de adquisición de ventajas económicas, es decir,

de manera instrumental o funcional por su aplicación en ámbitos directa o indirectamente productivos. El desmedro psicofísico de la persona, sobre todo el incapacitante, repercute cercenando o disminuyendo el poder de obtener ventajas -o evitar pérdidas- de significación patrimonial, así sea de manera difusa o a largo plazo, con independencia de una inmediata y concreta realidad productiva perjudicial. Es así que el resarcimiento del lucro cesante por incapacidad no se mide exclusivamente en función de un trabajo determinado sino atendiendo a las posibilidades genéricas de la víctima. De hecho, la jurisprudencia y doctrina mayoritarias entienden que no es requisito sine qua non para la procedencia de la indemnización por daños derivados de la integridad psicofísica, la prueba de merma en los ingresos o pérdida del trabajo remunerado. Zavala de González afirma que "el resarcimiento debe atender a las posibilidades productivas genéricas y no sólo una ocupación determinada, lo cual supone computar la inferioridad en que queda la víctima para reemplazar su actividad en caso de perder el trabajo actual. A ello se adiciona, en el caso de personas relativamente jóvenes o con capacitación, la mutilación de perspectivas de progreso y superación económica" (Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial, Solución de casos 7, Alveroni, Córdoba, 2010, p. 164). Sobre el punto, el Código Civil y Comercial incorporó la norma del art. 1746 que expresamente dispone que: "En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada". La doctrina señala que: "El mantenimiento o aumento de los ingresos luego de incapacitarse el damnificado es meramente contingente,

porque se basa en su situación al momento de dictar sentencia. De una situación circunstancial (no experimentar pérdidas o aumentar ganancias) no puede inferirse como regla que esa incapacidad no repercutirá disvaliosamente en el futuro. Por otro lado, no es únicamente el ingreso, igual o mayor, lo que determina el daño (en cuanto consecuencia), sino que lograr la misma o mayor utilidad le impone al incapacitado mayor contracción y esfuerzo de trabajo (...) Asimismo, (...) en caso de despido o de pérdida de la fuente de producción, deberá concurrir en inferioridad de condiciones compitiendo con otros con plena capacidad laborativa" (Sánchez Herrero, Andrés (Dir.), Tratado de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, La Ley, 2016, p. 228). De modo que, a consecuencia de lo señalado precedentemente, para que se posea el derecho a ser indemnizado por lucro cesante, no es necesario demostrar que la lesión incapacitante ha sido total, o que se ha perdido completamente la capacidad laborativa como tampoco la inexistencia de una actividad remunerada a consecuencia del hecho dañoso. En virtud de ello, el solo hecho de que el actor no haya acreditado tener ingresos concretos no constituye por sí misma una razón suficiente para privarlo de su derecho a obtener un resarcimiento en concepto de lucro cesante y proceder a reducirlo, transformándolo en un resarcimiento a título de pérdida de chances. Debido a que la incapacidad está destinada a prolongarse en el tiempo, no se trata sólo, ni fundamentalmente, de determinar las sumas ya dejadas de ganar (como se hace en el resarcimiento del lucro cesante pasado) sino las que se podrían ganar en el futuro. En esta tesitura, el empleo u ocupación del momento es una pauta

importante para medir la incidencia del daño, pero no un requisito indispensable o absoluto para determinar la efectiva presencia de un perjuicio económico real devenido por afectación de la capacidad laborativa. Como puede advertirse a partir de lo manifestado, entre el lucro cesante y el daño patrimonial derivado de una incapacidad sobreviniente, no existe una radical diferencia ontológicamente hablando. Puesto que en ambos casos se tiene en vista el menoscabo económico ínsito en la interrupción o limitación de la actividad productiva de la víctima del daño. Por ello es usual ver en las demandas de resarcimiento civil que se aluda al lucro cesante por lesiones de la integridad psicofísica de las personas, relacionándolo con el sufrido durante el período terapéutico; y se reserve la referencia al mismo daño como incapacidad, en conexión con el que se experimenta después de la etapa curativa, en la hipótesis de quedar secuelas aminorantes, como en el caso de autos, donde el damnificado porta una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 8%, tal cual lo determina el a quo en su sentencia. A los efectos de resarcir el daño sufrido, en conclusión, debe bastar que las lesiones incidan negativamente en la aptitud laboral, pues tal merma es suficiente para presumir una probable y correlativa disminución de ingresos futuros. Se ha dicho con razón, que "en nuestra sociedad el trabajo del hombre es fuente de riqueza y, por tanto, ésta suele hallarse ligada a la capacidad de aquél para ejercerlo" (Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial. Solución de casos 1, Alveroni, Córdoba, 1998, p. 180). El lucro cesante implica la mutilación de algún beneficio económico esperado. Esta noción inserta en el art. 1738 del CCC

resulta ser mucho más abarcativa que la consagrada en el Código de Vélez que consistía en una "ganancia del que fue privado el damnificado" (art. 1069) o "utilidad que haya dejado de percibir" (art. 519). Autorizada doctrina en la materia ha explicado que en el lucro cesante futuro se tiene en vista no sólo la privación de ingresos dinerarios sino, más ampliamente, la de ventajas materiales que podía alcanzar la víctima, aun en actividades no remuneradas y sin valor de cambio, si son útiles para sí misma o la familia. Supone un menoscabo genérico de potencialidades productivas de la persona. Por tanto, se atiende a repercusiones negativas en el porvenir, con abstracción de una concreta e inmediata realidad productiva perjudicial. No es menester probar que la víctima perdió su trabajo ni una disminución puntual de ingresos. Es suficiente que, ante la comprobación de una afectación perdurable de potencialidades productivas –en el sentido antes otorgado– se debe evaluar con amplitud la frustración de las potencialidades económicas de la víctima, con abstracción de una concreta e inmediata realidad laboral. En cuanto a su comprobación de alcance y existencia, y en la práctica, este rubro no puede probarse sino por inferencias, basadas en el sentido común y la experiencia. Ello es así, pues el hecho fuente ha detenido el curso de los acontecimientos en cuya evolución habrían podido obtenerse los beneficios, siendo imposible asegurar que se habrían alcanzado. La prueba debe suministrar convicción sobre una seria verosimilitud de conseguir las ganancias frustradas, aun sin seguridad sobre que se habrían logrado de no ocurrir el hecho lesivo (Zavala de González, La Responsabilidad Civil en el nuevo Código, Tomo II, pág. 555,

Alveroni Ediciones, año 2016). Continúa explicando la mencionada autora, que como supuesto de frecuente aplicación, nos encontramos con los incapacitados que no acreditan actividad retribuida, tal como resulta en este caso traído a resolver. Si se trata de incapacidades perdurables y con alguna significación, el resarcimiento no puede circunscribirse a una mera frustración de chances económicas, como lo ha considerado el juez de grado, puesto que se ha afectado la potencialidad productiva. Entiendo que es errado el argumento obstativo al reconocimiento de ese íntegro lucro cesante por no haberse probado actividad retributiva. Si bien esta postura restrictiva resultaría razonable atendiendo a un período terapéutico relativamente breve, no así en el caso de una incapacidad destinada a subsistir en el tiempo y que cercena posibilidades productivas en sentido amplio. Y es que en autos se ha acreditado que el actor padece de una incapacidad del 8%, la cual lo acompañará en su vida diaria de manera permanente tal como lo han dictaminado los peritos oficiales (ambos informaron que la incapacidad del actor es permanente y definitiva). De esta manera, se ha podido acreditar que el daño sufrido apareja un menoscabo de aptitudes humanas como fuente de ventajas económicas y no la mera chances o posibilidades de obtenerlas. Existe, en el caso concreto, la probabilidad objetiva de la obtención de un supuesto beneficio económico, pues no cabe duda de que el actor padece de una incapacidad permanente que le genera un efectivo perjuicio que debe ser reparado. Por el contrario, la doctrina tiene dicho, en postura que comparto, que la "chance" es la oportunidad, con ciertos visos de razonabilidad o fundabilidad, de lograr una ventaja o de evitar una



pérdida. Media por lo tanto, en la "chance" otro elemento cierto: la oportunidad está definitivamente perdida, la situación es irreversible y la "carrera" de concatenación causal y temporal, hacia la ventaja se ha detenido de manera inmodificable (Zavala de González Matilde, Doctrina Judicial Solución de casos 1, Alveroni Ediciones, Córdoba 1998, págs. 196 y sigs.). Además, y en cuanto a la prueba de este rubro, se ha dicho: "Conforme lo especificado en el escrito introductorio, en realidad, pese a la denominación dada, este rubro refiere a una pérdida de chance por posibles futuras mejoras en la prestación laboral de la víctima que, dice, perdió como consecuencia del accidente. Que en autos no encontramos ninguna prueba que acredite el extremo invocado al peticionar este ítem resarcitorio. No se demostró, en efecto, que M. hubiera tenido alguna chance cierta, concreta, y puntual, de ascenso o de otro progreso en la esfera laboral. Ciertamente es que M. admitió estar realizando tareas pasivas, pero ello no representa, por sí mismo, una retracción en sus expectativas laborales. El lucro cesante se puede pedir cuando se prueba fehacientemente que ha dejado de percibir una suma cierta y determinada que debía haber ingresado por un concepto comprobable (ej. laboral). Es decir, cuando se deja totalmente de trabajar en una actividad rentada, cesando su pago en forma total. En el caso no se ha probado tal circunstancia. Es más, el actor, al absolver posiciones, dijo que siguió cobrando normalmente. Pero no es lo mismo el lucro cesante, como montos dejados de percibir, que la pérdida de chance, con relación a una suma que, eventualmente, pudiera haber recibido ante una oportunidad futura, pero cierta. Así coincidimos con Mosset Iturraspe en

que debe indemnizarse cuando este rubro es "cierto" (...) Si bien en la chance permanece hipotética e incierta la efectiva concreción, la ganancia posible, ya que nunca se sabrá si realmente, de no haber ocurrido el accidente se hubiera en verdad alcanzado, hay elementos que sí se deben demostrar. El punto a que se dirige la prueba, en este rubro, es a la posibilidad misma, a la chance en sí, es decir al conjunto de condiciones ciertas que puedan hacer presumir, con algún viso de certeza y convicción suficientes, que el progreso (económico o espiritual) iba a suceder. (...) En este caso en examen, la parte actora se ha limitado únicamente a exponer la posibilidad de progreso, sin especificar en qué consistía la misma, qué chance cierta tenía al respecto y por qué ello se ha perdido. La sola circunstancia de las tareas pasivas, por sí sola, no alcanza para demostrar una chance perdida. Que, en consecuencia, este rubro no puede prosperar y se rechaza" (Trib. Coleg. Resp. Extrac. N° 1 de Santa Fe, 1° Secr., "M. C/ P.", res. 112, fo. 160/94, t. 55, citado en Revista de Derecho de Daños, Chances, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2008, pág. 405 y sig.). De lo dicho hasta aquí surge con claridad que para que una "chance" sea considerada resarcible es menester que se haya probado su existencia, y además es necesario acreditar que se ha perdido definitivamente debido al hecho que ha causado el daño. Lo cual no se configura en autos, ya que en primer lugar no lo ha denunciado el actor, y porque tampoco surge de las constancias de autos que el actor haya tenido la posibilidad cierta de acceder a algún trabajo en particular. En definitiva, de la prueba colectada en autos se desprende –y no ha sido materia de agravio – que, como consecuencia del

accidente ocurrido, el accionante sufrió daños en su persona que han afectado su integridad psicofísica. Estos daños han sido descriptos por el magistrado de grado a fs. 361 y 361 vta., por lo que a ello remito brevitatis causa. Además, dada la edad del damnificado a la fecha del hecho (44 años), su medio de vida entre el hecho y la sentencia - trabajo informal- no puede de ningún modo considerarse inalterable, restándole casi 28 años de promedio de vida útil estimada si tomamos, como tal, el tope de 72 años fijado en demanda por el accionante, admitido jurisprudencialmente, y utilizado por la a quo para el cálculo del monto indemnizatorio, todo lo cual ha sido ajeno a la materia de agravios. En función de ello tratándose de una afectación perdurable de potencialidades productivas que pesa sobre el actor con motivo del hecho lesivo, y evaluando con amplitud la frustración de las potencialidades económicas de la víctima, con abstracción de una concreta e inmediata realidad laboral –en consonancia con la tesitura antes expuesta –, teniendo a su vez en cuenta la edad del damnificado, corresponde acoger el rubro peticionado como lucro cesante sin aplicación de reducción alguna en concepto de pérdida de chances, debiéndose revocar la sentencia impugnada en cuanto así lo hace. 2. Segundo Agravio. Salario Mínimo Vital y Móvil. Se agravia el recurrente por cuanto el a quo efectuó los cálculos matemáticos para la cuantificación del daño por pérdida de chance en base al monto correspondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del hecho (diciembre del 2011). Así planteado el agravio, corresponde destacar que el Sr. juez de primera instancia determinó que: "En cuanto a los ingresos, teniendo en cuenta que el actor, tal como

fue manifestado en el escrito inicial, al momento del hecho y en la actualidad mantiene una relación laboral no formal, corresponde tomar como parámetro para el cálculo del presente epígrafe, el salario mínimo vital y móvil, tal como el propio actor lo solicita, pero a la época de producción del siniestro base de la acción, el que ascendía a la suma de dos mil trescientos pesos (\$ 2.300), según Resolución 3/2011 del Consejo Nacional del Empleo, La Productividad y El Salario Mínimo, Vital y Móvil, a la que se debe aplicar un porcentaje estimativo en concepto de frustración de chance (...) Conforme a ello, estimo que dicha suma es la que debe tomarse en definitiva como ingreso promedio del actor para efectuar el cálculo pertinente, reducida al cincuenta por ciento (50%) por tratarse de pérdida de chance conforme las circunstancias de este caso, y sobre éste aplicar el grado de incapacidad estimado por los peritos médicos oficiales del 8% de la total de la capacidad humana. En cuanto al lapso total de períodos, debe calcularse desde la fecha del evento dañoso (31/12/2011) y hasta la edad estadísticamente estimada de vida útil laborativa (72 años), atento que el daño en cuanto a la pérdida de oportunidades ha sido desde el momento mismo del hecho y por cuanto se indemniza un daño tanto presente como futuro, que es la pérdida de chance de una persona que ve disminuida su posibilidad de realizar las tareas que le resultan habituales, teniendo en cuenta que el perjuicio ocasionado trasciende a los demás aspectos de la vida de relación". En definitiva, el a quo calculó la indemnización por pérdida de chance teniendo en cuenta el valor del SMVM a la fecha del siniestro. Ahora bien, en los presentes no se encuentra controvertida la utilización

de la fórmula Marshall. Cuando se realiza la distinción entre lucro cesante anterior a la sentencia o pasada y lucro cesante posterior o futuro, la fórmula Marshall suele reservarse para el cálculo del lucro cesante futuro. No obstante, a mi criterio, no existe ninguna razón jurídica –al menos, no si lo consideramos para la generalidad de los casos y en abstracto – que impida que la fórmula Marshall sea utilizada para el cálculo del total de la indemnización a partir de la fecha de producción del daño, sin efectuar una distinción entre aquello que es anterior y aquello que es posterior a la sentencia. Así las cosas, en el caso concreto, en virtud de que la distinción entre períodos pasados y futuros no se condice con lo demandado en autos y con lo resuelto por el juez de primera instancia y que esa distinción, si bien posible, no resulta necesaria –conforme lo ya expuesto –, considero que debe practicarse una única fórmula que comprenda todo el perjuicio sufrido desde la fecha del hecho. Esto no implica desconocer que, en otros supuestos, pueda aplicarse acertadamente el método de cálculo que ha introducido el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba in re "Navarrete". Sin embargo, reitero, entiendo que ello no procede en estos autos y a esta altura del proceso, atento no haber mediado petición de parte en tal sentido (art. 330, CPCC) y resultar la fórmula Marshall idónea como método de cálculo de resarcimiento a la víctima. Bajo esta premisa y con relación a lo planteado, corresponde precisar que si a los fines de la determinación de la indemnización en función de la incapacidad de la víctima el juez de primera instancia tomó la fórmula "Marshall" y no distinguió entre lucro cesante pasado y futuro, el período indemnizatorio principia desde la fecha del hecho y por tanto los

parámetros utilizados para el cálculo deben ser los de la fecha de dicho evento. Por esta razón, considero que no resulta adecuado tomar el valor del SMVM al momento de la sentencia de primera instancia, tal como lo solicita el recurrente, en este caso concreto. Sin perjuicio de ello, no se puede soslayar que la depreciación de la moneda nacional en el tiempo transcurrido entre la fecha del hecho (2011) y la decisión de primera instancia (2020) ha sido de una magnitud que, si el juez hubiera impuesto intereses desde la fecha de la sentencia, importaría una condena insuficiente, desajustada de las variables que la justifican. Y, por cierto, otorgar una indemnización que se encuentre completamente desfasada respecto del valor real en que debe estimarse un justo resarcimiento implica dar la espalda no sólo al principio de reparación integral sino también a la realidad económica y social, violentando de este modo las más elementales pautas de justicia que deben guiar una decisión jurisdiccional. En consecuencia, es preciso optar entre las diversas alternativas válidas de mecanismos indemnizatorios que no impliquen incurrir en una desvalorización del poder adquisitivo del resarcimiento monetario a percibir por el damnificado. Ello ha sido contemplado por el a quo, ya que sin perjuicio de que realizó el cálculo con base en el SMVM vigente a la fecha del hecho, le aplicó intereses desde la fecha del siniestro, y no sólo a tasas puras. De esta manera, el desfase producido por la distorsión inflacionaria ha quedado salvado con la aplicación de aquellos, razón por la cual la aplicación de un SMVM con valor a la fecha de la sentencia sería innecesaria a la luz de los fundamentos esgrimidos en el agravio por parte del actor. En función de ello, considero que el criterio optado

por el a quo con relación a la utilización del valor del salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del siniestro con la aplicación de intereses desde dicho momento resulta adecuada, razón por la cual el segundo agravio planteado por el recurrente debe rechazarse. VII. Por las razones dadas, la solución correcta, a la luz de las constancias de la causa y el derecho aplicable, es hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y hacer lugar a lo demandado en calidad de lucro cesante, para lo cual debe estarse a la suma a la que arribó el magistrado de grado a través de la fórmula Marshall sin proceder a la reducción del 50%, lo cual asciende al monto de \$33.991,68, con más intereses judiciales desde la fecha del siniestro (31/12/2011) (tasa pasiva del BCRA con más un 2% nominal mensual) según lo establecido por el Sr. juez de Primera Instancia, y confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios. VIII. Costas y honorarios de primera instancia conforme nueva resolución: [Omissis] IX. Conclusión: Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Oscar Ignacio Reyna en contra de la sentencia N° 48 de fecha 22/4/20 y en su mérito: 1) Dejar sin efecto lo resuelto en la sentencia apelada en cuanto al acogimiento del lucro cesante como pérdida de chance. Hacer lugar a la demanda en concepto de lucro cesante por la suma de \$33.991,68, con más intereses equivalentes a la tasa pasiva del BCRA con más un 2% mensual desde la fecha del hecho lesivo (31/12/11) y hasta su efectivo pago. 2) Adicionalmente corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios del letrado de la parte actora y regular al Dr. Diego Carlos Moyano en concepto de honorarios la suma

de pesos sesenta y tres mil setecientos diecisiete con setenta y dos centavos (\$63.717,72), por sus labores realizadas en primera instancia. Dichos estipendios devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva del BCRA con más el 2% mensual desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta su efectivo pago.

3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios. X. Costas y honorarios de segunda instancia: [Omissis].

Los doctores Rafael Garzón y Ricardo Javier Belmaña adhieren al voto emitido por el Sr. Vocal preopinante.

Por ello, y el resultado obtenido por el acuerdo celebrado,

SE RESUELVE: 1) al 3) [Omissis]. 4) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Oscar Ignacio Reyna en contra de la Sentencia N° 48 de fecha 22/4/20 y en su mérito: Dejar sin efecto lo resuelto en la Sentencia apelada en cuanto al acogimiento del rubro petitionado como lucro cesante como pérdida de chance con la reducción del 50%. En consecuencia, corresponde acoger el reclamo por lucro cesante mandando a pagar por dicho rubro en la suma de pesos treinta y tres mil novecientos noventa y uno con sesenta y ocho centavos (\$33.991,68), con más intereses equivalentes a la tasa pasiva del BCRA y un 2% mensual desde la fecha del hecho lesivo (31/12/2011) y hasta su efectivo pago. Las costas de primera instancia se mantienen en un 100% a cargo de las demandadas



y citada en garantía. Adicionalmente corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios del letrado de la parte actora y reemplazarla por lo siguiente: [Omissis]. Se confirma el resolutorio atacado en todo lo demás que ha sido materia de agravios. 5) Imponer las costas devengadas en segunda instancia y con motivo de la apelación del accionante, en un 20% al actor Oscar Ignacio Reyna y un 80% a los demandados Sres. Sebastián Cúneo y Roberto Damián Barrionuevo, haciéndola extensiva a la citada en garantía Liderar Cía. Gral. de Seguros SA. 6). 7). 8). [Omissis].

Jorge Augusto Barbará – Ricardo Javier Belmaña – Rafael Garzón Molina